

予備独自問題 R2-18

(配点：2)

月 日

月 日

次の学生AないしDの【会話】は、医師が捜査機関の依頼に基づき、人の身体から注射器を用いて直接強制により血液を採取するために必要と考えられる令状に関する議論である。学生AないしDが必要と考えている令状として正しい組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A：私は、一般に身体内にある体液を採取するために必要な令状については、強制採尿に関する判例が採用した考え方と同じでよいと思う。

学生B：しかし、同じ体液といっても、尿と血液とでは性質が全然違うからなあ。

学生C：そういうBさんの見解も、対象者が採血を拒否した場合には直接強制するための明文がないのが問題だ。

学生B：その点は、刑事訴訟法第172条の類推適用で対応できると思う。

学生D：Cさんの見解だって、もともとその令状が想定している範囲は、身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であって、身体の損傷を伴う血液の採取をその令状で行い得とするのは行き過ぎだ。

学生C：そういうDさんの見解も、それぞれの令状が単独ではできないことを、令状を併用すればできるとするのは、便宜に過ぎるのではないかと批判されているよね。

学生D：でも、Bさんの見解のように、直接の明文規定を欠いているにもかかわらず、条文の類推適用によって直接強制し得るとするよりは良いと思う。

1. A：搜索差押許可状及び鑑定処分許可状、B：鑑定処分許可状、C：身体検査令状、D：搜索差押許可状及び身体検査令状
2. A：搜索差押許可状、B：身体検査令状、C：鑑定処分許可状、D：鑑定処分許可状及び身体検査令状
3. A：搜索差押許可状、B：身体検査令状、C：鑑定処分許可状、D：搜索差押許可状及び身体検査令状
4. A：搜索差押許可状、B：鑑定処分許可状、C：身体検査令状、D：鑑定処分許可状及び身体検査令状
5. A：搜索差押許可状及び鑑定処分許可状、B：身体検査令状、C：鑑定処分許可状、D：鑑定処分許可状及び身体検査令状

学生AないしDが、医師が捜査機関の依頼に基づき、人の身体から注射器を用いて直接強制により血液を採取するために必要と考えている令状は、1から5の記述によれば次の6通りがある。

I 搜索差押許可状 (218 条 1 項前段)、II 身体検査令状 (218 条 1 項後段)、III 鑑定処分許可状 (225 条 3 項)、IV 搜索差押許可状及び身体検査令状、V 搜索差押許可状及び鑑定処分許可状、VI 鑑定処分許可状及び身体検査令状

以下各学生がいかなる見解に立つのかについて検討する。

学生A

Aは、身体内にある体液採取に必要な令状は、強制採尿に関する判例が採用した考え方と同じでよいと発言している。そして、判例 (最決昭 55.10.23、百選 28 事件) は、強制採尿をするために必要な令状は、搜索差押許可状 (218 条 1 項前段) であるとする。したがって、Aが必要と考えている令状は、I 搜索差押許可状である。

学生B

Bの第一発言によれば、Bは、同じ体液といっても、尿と血液とは性質が全然違うと考えていることがわかる。そうすると、Bが必要と考えている令状は、搜索差押許可状ではない。そして、Cの第一発言によれば、Bの見解は、対象者が採血を拒否した場合には直接強制するための明文がないのが問題だとされている。この点、直接強制するための明文がないのは鑑定処分許可状である。したがって、Bが必要と考えている令状は、III 鑑定処分許可状である。

学生C

Dの第一発言によれば、Cが必要と考えている令状によりなし得る行為の範囲は、身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であることがわかる。鑑定処分許可状によれば、身体の内奥まで及ぶ検査も許されるのに対し、身体検査令状では、身体の外表や体腔を外部から確認する程度のことしかなし得ない。よって、Cが必要と考えている令状は、II 身体検査令状である。

学生D

Cの第二発言によれば、Dの見解は、それぞれの令状が単独ではできないことを、令状を併用すればできるとするのは、便宜に過ぎるのではないかと批判があることがわかる。そして、このような批判が妥当するのは、身体の内奥まで及ぶ検査も許されるが、直接強制のための明文規定がない鑑定処分許可状と、身体の外表や体腔を外部から確認する程度のことしかなし得ないが、直接強制ができる身体検査令状を併用する見解である。したがって、Dが必要と考えている令状は、VI 鑑定処分許可状及び身体検査令状である。なお、IV 搜索差押許可状及び身体検査令状の併用は、搜索差押許可状も身体検査令状も直接強制の手段を有するので、学生Cの第二発言の「それぞれの令状が単独ではできないことを、令状を併用すればできるとするのは、便宜に過ぎる」との批判に当てはまらず、Dの見解ではない。また、V 搜索差押許可状及び鑑定処分許可状の併用は、直接強制の手段を有する搜索差押許可状と、その手段を有しない鑑定処分許可状を併用するものであり、学生Cの第二発言の「それぞれの令状が単独ではできないことを、令状を併用すればできるとするのは、便宜に過ぎる」との批判が当てはまるが、1から5の記述のDの中に、「搜索差押許可状及び鑑定処分許可状」とするものは存在しないから、Dの見解ではない。

以上より、各学生の立つ見解は、A：搜索差押許可状、B：鑑定処分許可状、C：身体検査令状、D：鑑定処分許可状及び身体検査令状であり、正解は肢4となる。